

1500014-51.2022.8.26.0611

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... das drogas e agia em nítida ação de tráfico de drogas. Com efeito, os policiais relataram que realizaram campana em operação contra o tráfico de drogas na região. Visualizaram e filmaram o réu vendendo drogas a um usuário e, logo após a mercancia, abordaram o comprador LUIS RICARDO.

Com ele, encontraram dois pinos de cocaína e, conquanto em seu depoimento em juízo seja no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500014-51.2022.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500014-51.2022.8.26.0611

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Ministério Público

Réu:

Matheus Cesar Zulato

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo acusa MATHEUS CESAR ZULATO de praticar o crime tipificado no artigo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De acordo com a denúncia, no dia a 05 de janeiro de 2022, por volta de 16h50, na Rua Jorge Balan, em frente ao numeral 629, nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, MATHEUS CESAR ZULATO teria vendido 02 (dois) pinos contendo cocaína (*Erythroxylum coca*), ao usuário Luís Ricardo de Lima Colombari, bem como supostamente mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 07 (sete) pinos contendo cocaína (*Erythroxylum coca*), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (f.148/151)

O acusado foi preso em flagrante delito. O Juiz de Direito do plantão judiciário da 40ª Circunscrição Judiciária homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado (f. 95/97).

O acusado apresentou resposta à acusação (f. 155/156).

Decisão de f. 159/162 recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado. Na mesma oportunidade, o Ministério Público apresentou suas alegações finais e pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da inicial acusatória. A defesa técnica, por sua vez, apresentou suas alegações finais orais, requerendo a absolvição do acusado com base no princípio in dubio pro reo; subsidiariamente pugnou pela desclassificação do delito do artigo 33 da lei 11.343/06, para o delito do artigo 28, da mesma lei (f.239/243).

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido. O Ministério Público acusa MATHEUS CESAR ZULATO de praticar o crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que cuida do denominado delito de "tráfico de drogas" possui a seguinte redação:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

De início, consigna-se que ação deve ser julgada procedente.

A cláusula do devido processo legal e o princípio da presunção de inocência exigem que o órgão oficial de acusação suporte o inteiro ônus da prova de culpabilidade do réu, além de uma dúvida razoável (beyond a reasonable doubt). A mera dúvida resolve o processo em favor do acusado. "A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.", consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.

A materialidade do crime ficou assentada pelo auto de prisão em flagrante de f. 01/02, pelo boletim de ocorrência de f. 08/11, pelos autos de exibição e apreensão de f. 14/16 e 54, pelas fotografias de f. 17/19 e 62/63, pelo vídeo de f. 64, pelos autos de constatação de f. 21/23 e 58/60, bem como pelos laudos periciais de f. 137/138 e 139/141, tudo a convergir de forma insofismável que a substância apreendida no curso da investigação policial é o narcótico cocaína, proscrito pela legislação brasileira.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o acusado, senão vejamos:

A testemunha ADEVANDRO ALVES DA SILVA, policial civil ouvido em juízo, relatou que receberam a informação de que o acusado estava traficando. Após "campana", abordaram um usuário que havia comprado entorpecentes com o réu. Posteriormente, deslocaram-se até a residência de MATHEUS e, no local, o acusado apontou que no interior de uma impressora estavam 07 (sete) "pinos"; segundo ele para consumo

próprio. O usuário supracitado estava em um veículo GOL de cor branca e o momento em que adquiriu os entorpecentes foi registrado por câmeras. O réu é conhecido nos meios policiais; em seus bolsos foi encontrada a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) e em sua carteira R\$220,00 (duzentos e vinte reais). O usuário teria dito que pagou por 02 (dois) "pinos" a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e que havia adquirido os itens há pouco tempo (mídia digital).

A testemunha PEDRO THIMÓTEO DA SILVA, policial civil ouvido em juízo, relatou que após receberem informações sobre a venda de drogas por parte do acusado, montaram "campana" próxima à sua residência. Visualizaram um veículo, MATHEUS entrou na residência e, ao retornar, entregou algo ao condutor do carro. Durante a abordagem do usuário, ele revelou que havia adquirido 02 cápsulas por R\$ 50,00. Na residência do réu formaram encontradas 07 (sete) cápsulas no interior de uma impressora (mídia digital).

A testemunha LUIS RICARDO DE LIMA COLOMBARI, ouvido em juízo, relatou que no dia dos fatos foi abordado por policiais e que os "pinos" encontrados adquiriu com alguns "meninos" que costumam ficar em um pasto, no Bairro João Paulo II. A pessoa de quem comprou tem o apelido de "orelha". Conhece o acusado "de vista". No dia dos fatos, foi até a casa de MATHEUS, pois havia prestado um serviço para o genitor do acusado e pretendia receber seu pagamento. A droga encontrada com ele havia sido adquirida horas antes, em um local onde existe uma quadra abandonada e um pasto. Os pinos eram grandes, de cor azul (mídia digital).

A testemunha ROBSON DOS SANTOS MARTINS, ouvido em juízo, é vizinho do acusado e visualizou o momento em que o réu entregava quantia em dinheiro para uma pessoa que parou seu veículo no local. O indivíduo que estava no interior do veículo havia feito serviço nas calhas do local (mídia digital).

O acusado MATHEUS CESAR ZULATO, interrogado em juízo, relatou que no dia dos fatos estava à porta de sua casa, na companhia de três amigos, LUIS RICARDO foi até o local com o intuito de receber quantia relativa à serviços de encalhamento prestados. O interrogado entregou a quantia de R\$150,00 (cento e cinquenta) e permaneceu no local. Cerca de 10 (dez) minutos após os fatos a polícia dirigiu-se até o local questionando sobre drogas. Os agentes adentraram a residência, sem qualquer gênero de autorização e, lá reviraram os móveis e ameaçaram prender seu genitor por conta de uma luz solar e sua criação de pássaros, mediante a tal situação o réu revelou que possuía 2 (dois) pinos para consumo próprio no interior de uma impressora. O dinheiro apreendido é proveniente de seu trabalho de técnico em som automotivo e insufilm Não conhece LUIS RICARDO .Os policiais ameaçaram seu genitor, apontando que uma luz solar encontrada no local era proveniente de furto. Uma porção de maconha pertencente a seu irmão, para consumo próprio, também foi encontrada no local. (mídia digital).

Este é o teor da prova oral colhida em juízo.

Os policiais foram claros e demonstraram com fidelidade a narrativa dos fatos, bem como a apreensão em flagrante do acusado tendo em depósito as drogas apreendidas. O ato de mercancia está evidenciado pelo vídeo de f. 64, pela fotografia de f. 63, a qual denota os dois pinos de cocaína encontrados com o usuário após a abordagem e os sete pinos apreendidos na casa do réu. É possível observar a nítida semelhança na forma de acondicionamento do entorpecente, sendo que os laudos periciais definitivos atestaram que as substâncias são positivas para o composto químico METIL BENZOIL ECGONINA -cocaína - (f. 137/138 e 139/141), que se encontra relacionada na Lista "F" da Portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como drogas e entorpecentes de uso proscrito no Brasil.

Nessa quadra, joeirado o acervo probatório, tenho que ficou provado que o acusado era o proprietário das drogas e agia em nítida ação de tráfico de drogas. Com efeito, os policiais relataram que realizaram campana em operação contra o tráfico

de drogas na região. Visualizaram e filmaram o réu vendendo drogas a um usuário e, logo após a mercancia, abordaram o comprador LUIS RICARDO.

Com ele, encontraram dois pinos de cocaína e, conquanto em seu depoimento em juízo seja no sentido de que comprou a droga de outra pessoa e em lugar diverso, sua alegação resta isolada nos autos. Ato contínuo, os agentes públicos dirigiram-se à residência do réu, o qual indicou esconder sete pinos de cocaína dentro de uma impressora. O entorpecente foi apreendido, juntamente com dois celulares e dinheiro proveniente do tráfico de drogas (f. 14/16).

Consigno que não há nulidade da prova por ofensa ao direito de inviolabilidade asilar, a considerar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Com efeito, não há ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio, quando da prisão em flagrante estava em situação de flagrância e havia fundada suspeita da ocorrência da infração penal, seja pela flagrância do ato de venda, seja pela localização de drogas na residência do acusado MATHEUS.

Segundo prescreve o art. 5º, XI, da Carta Maior, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Como se percebe, há 04 (quatro) exceções à inviolabilidade do domicílio: a) flagrante delito; b) desastre; c) prestação de socorro; e d) determinação judicial. Convém lembrar, também, que, de acordo com o magistério jurisprudencial do STF, o conceito de "casa" é amplo, abarcando (i) qualquer compartimento habitado (casa, apartamento, trailer, barraca); (ii) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva (hotel, apart-hotel, pensão); ou (iii) qualquer compartimento privado onde alguém exerça profissão ou atividade, incluindo as pessoas jurídicas (Bernardes e Ferreira, in Direito Constitucional - Tomo II). De outra banda, é majoritário, outrossim, o entendimento de que o termo "dia", para fins dessa garantia constitucional, segue critério físico-astronômico, compreendendo o interregno que vai da aurora ao crepúsculo.

Feito esse breve exórdio, verifico que o Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido de que a exceção à inviolabilidade domiciliar em razão de flagrante delito - que, recorde-se, pode ocorrer mesmo no período noturno - deve estar arrimada em fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º), devidamente justificadas 'a posteriori', hábeis a indicar que no interior na casa se está praticando algum crime, é dizer, em estado de flagrante delito. Com isso, quis o Supremo equacionar o direito dos cidadãos e a proteção aos agentes de segurança pública. Noutras palavras, mesmo que durante a invasão domiciliar não se tenha constatado a ocorrência de um crime em flagrante, não haverá ilicitude na conduta dos agentes policiais se apresentarem as fundadas razões que os levaram a ingressar naquela casa, o que, sem dúvida, deve ser objeto de controle - mesmo que 'a posteriori' - por parte da própria polícia e, claro, pelo Ministério Público (a quem compete exercer o controle externo da atividade policial, nos termos do art. 129, VII, da CF) ou mesmo pelo Judiciário, ao analisar-se a legitimidade de eventual prova colhida durante essa entrada à residência.

Vejamos a ementa do referido julgado:

EMENTA: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição

não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

De fato, as informações prestadas pelos policiais são contundentes, ao passo que os depoimentos das testemunhas de defesa não encontram lastro probatório. PEDRO alegou ter visto MATHEUS entregando um dinheiro a LUIS RICARDO, em virtude de um serviço prestado na residência. Todavia, inexiste real comprovação do serviço e também não é crível que os policiais estejam mentindo.

A prova deve ser valorada dentro do contexto em que ocorreram os fatos, com os pés no chão e olhos na realidade, valorizando-se os indícios, que sempre foram reconhecidos como elementos de convicção.

Urge assentar que os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso).

De mais a mais, sabe-se que a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função investigativa, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço. Sobre a validade dos testemunhos insuspeitos dos policiais, vejamos a farta orientação jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Desconstituir o julgamento da Corte a quo, que condenou as agravantes pelo crime de tráfico de drogas, ou aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, demandaria a incursão na seara fático/probatória, situação inviável ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONSIDERADO NOTÓRIO. COTEJO ANALÍTICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAIS. VALIDADE.
2. O alegado dissenso pretoriano deve ser demonstrado conforme preconizado nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, mesmo em se tratando de dissídio considerado notório.
3. É entendimento já há muito pacificado neste Sodalício, de que são válidos os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 482.641/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 08/10/2014)

Os testemunhos dos policiais estão em harmonia com as provas produzidas, especialmente pelo laudo toxicológico, que atestou que os materiais apreendidos se tratam de cocaína.

Ainda sobre a credibilidade do testemunho dos policiais militares, julgo apropriado rememorar a preleção do Ministro CELSO DE MELLO:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF - HC - 74.608-0 - de São Paulo - rel. Min. Celso de Mello - DJU 11.04.97, pág. 12.189).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o fato de o acusado, ao ser surpreendido na posse de drogas, após denúncia, é suficiente para justificar o desfecho condenatório, quiçá quando há testemunhas oculares da mercancia.

A propósito, colho os seguintes precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo:

EMENTA: Tráfico de entorpecentes. Policiais militares que, após denúncia anônima de que um indivíduo estaria praticando tráfico de entorpecentes, dirigem-se até o local, onde avistam o réu, que trajava as mesmas roupas informadas pela denúncia. Milicianos que permanecem escondidos atrás de uma cerca viva, oportunidade em que visualizam a aproximação de um rapaz em uma motocicleta, que conversa com o acusado e então passa a dar voltas no quarteirão. Réu que se dirige até um banco de areia localizado em um terreno baldio e, ao retornar, entrega droga ao rapaz da motocicleta, que levanta o "eppendorf" contra a luz, permitindo que os policiais constatem se tratar de cocaína. Policiais que decidem realizar a abordagem, momento em que avistam o réu recebendo dinheiro de outro indivíduo, que se encontrava no interior de um veículo e fugiu ao perceber a presença da polícia. Apreensão da quantia de R\$ 11,50 no bolso do acusado, e de 44 porções de cocaína, que se encontravam no referido banco de areia. Palavras dos policiais coerentes e seguras, dando conta da apreensão das drogas. Negativa do acusado isolada. Postura de quem se valia da droga para a mercancia. Condenação de rigor. Desclassificação inviável. Penas bem dosadas. Hipótese que não autorizava mesmo a redução pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Impossibilidade de substituição da pena. Regime fechado adequado (Lei n.º 11.464/07). Apelo improvido. (Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Araras; Órgão julgador: 7ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 12/04/2017; Data de registro: 12/04/2017)

EMENTA: Tráfico de Entorpecentes. Policiais militares que, após diversas denúncias anônimas recebidas pela polícia civil e militar dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes, receberam a notícia de que ele estaria embalando e comercializando drogas na praça central da cidade, dirigindo-se até o local. Acusado que, ao perceber a aproximação dos milicianos, foge em direção a uma escola e, na iminência de ser detido, joga duas porções de cocaína em seu interior. Em revista pessoal, os policiais localizam embalagens plásticas vazias e um aparelho celular. Posteriormente, ao entrarem na escola, encontram as porções de cocaína. Os policiais ainda refazem o caminho percorrido pelo réu durante a perseguição, ocasião em que localizam outras duas porções de substância aparentando ser cocaína, além de uma tesoura. Palavras dos agentes públicos coerentes e seguras. Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Prova oral hábil. Condenação pelo tráfico bem decretada. Penas revistas, afastado o aumento da base e aplicado, excepcionalmente, o redutor do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em 1/2. Regime fechado absolutamente necessário. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido. (Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Monte Alto; Órgão julgador: 7ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 12/04/2017; Data de registro: 12/04/2017)

EMENTA: Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de droga e denúncia anônima – Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva – Apelo parcialmente provido. (Relator(a): Rachid Vaz de Almeida; Comarca: São Joaquim da Barra; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 23/02/2017; Data de registro: 01/03/2017).

Percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

A tese defensiva de que as drogas eram para uso próprio não merece prosperar. Além do ato de venda ter sido testemunhado pelos policiais, o artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de ter em depósito a droga já configura o tipo penal,

e as circunstâncias em que o fato veio à tona, o modo de acondicionamento e o fato de os entorpecentes terem sido encontrados com um usuário logo após ir à residência do acusado convergem no sentido de que houve tráfico de drogas.

Destarte, todos esses elementos somados ao fato de que as drogas foram encontradas tanto com o usuário, quanto com o vendedor; o dinheiro apreendido; o mesmo modo de acondicionamento dos entorpecentes; e os laudos de f. 137/138 e 139/141, deságuam com segurança o propósito de mercancia e de difusão ilícita das drogas, não obstante, enfatizo, o tipo penal do artigo 33 ser congruente.

Dessa forma, as versões do réu, da defesa técnica e suas testemunhas estão em confronto direto com o acervo probatório, máxime os testemunhos policiais e laudo pericial, revelando seu inequívoco engajamento no comércio de drogas. Assim, tendo ficado demonstradas a autoria e a materialidade do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a condenação é de rigor, não havendo o que se falar em fragilidade da autoria.

Ainda, julgo incabível reconhecer a figura do tráfico privilegiado, na forma do § 4º do artigo 33, porque as evidências comprovam a dedicação do réu ao tráfico de drogas, com ação planejada e refletida, o que foi corroborado pelos depoimentos dos agentes públicos, os quais afirmaram que MATHEUS é conhecido nos meios policiais pela prática desse delito, além de ele possuir uma condenação em segunda instância pelo crime de tráfico, conforme se depreende dos autos do processo 1500956-11.2019.8.26.0572 (f. 67/68).

Dessa forma, o acusado não se trata de traficante episódico ou eventual, mas sim de traficante engajado em atividade criminosa, escapando, por consequência, da referida causa de diminuição de pena.

Assentado o tráfico de drogas, todas as evidências demonstram que o dinheiro apreendido é proveito do tráfico, pelo que deve ser decretado seu perdimento. Quando a Defesa tomou conhecimento do auto de exibição e apreensão, poderia ter demonstrado a origem lícita do numerário, até sentença final, o que não ocorreu. A alegação de que se trata de quantia oriunda de seu labor não foi comprovada pelo conjunto probatório. O réu foi visto em típica ação de venda, situação que implica no reconhecimento da ilicitude do montante apreendido.

O perdimento do dinheiro é corolário lógico, na forma determinada pelo artigo 63, § 1º, da Lei Federal 11.343/06, e até mesmo em função do art. 92, II, letra a e b, do Código Penal. Não há provas seguras da origem lícita do dinheiro, o que autoriza, a princípio, a conclusão de que é produto do crime de tráfico, não desincumbindo-se o acusado do ônus que lhe competia de provar o contrário.

Por outro laudo, a considerar que não há qualquer evidência de que os aparelhos celulares apreendidos foram utilizados como instrumentos do crime, conforme o laudo pericial de f. 223/234, cabível a liberação, nos termos do artigo 63, inciso II, da Lei Federal 11.343/06.

Ante o exposto, conclui-se pela procedência da ação nos termos da denúncia.

III - DISPOSITIVO

Por esses fundamentos, condeno MATHEUS CESAR ZULATO nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal do acusado, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Ausentes circunstâncias judiciais negativas (artigo 59 do Código Penal), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

Não estão satisfeitos os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, como já fundamentado.

Fica o réu definitivamente condenado à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP) em razão da pena fixada.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por não vislumbrar motivos contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias na Delegacia de Polícia, determino que, caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independentemente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.

Determino, outrossim, o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido, nos termos da Lei nº 11.343/06, a ser comunicado após o trânsito em julgado. Com relação aos celulares apreendidos, a restituição é a medida que se impõe.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP). Transcorrido o referido prazo *in albis*, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do artigo 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.

b) Expeça-se Guia de Execução Penal de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente, outra ao diretor do estabelecimento prisional onde o réu deve cumprir a pena e outra ao Conselho Penitenciário.

c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

d) Oficie-se a SENAD a respeito do perdimento.

e) Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 01º de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA